

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

המבקשת: **שרה (ג'וי) שפירא**
ע"י ב"כ עו"ד א. שינדלר ושות'
רחוב הסורג 1, ירושלים.

נ ג ד

המשיבים: 1. **יעקב אריה**
2. **נחמה אריה**
ע"י ב"כ עו"ד י. הומינר ושות'
רחוב בני ברית 1, ירושלים.

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בתביעה למתן צו עשה וצו מניעה קבוע המורה לנתבעים, בעליה של דירה המצויה מעל דירתה של התובעת, להרוס את כל הפיגומים שנבנו לצו רך בניית תוספת ולהחזיר את המצב לקדמותו וכן לאסור עליהם לבנות בשטח הרכוש המשותף.

תביעה זו נשמעה בפני כבוד המפקח הבכיר (בדימוס) מר פנחס לוי. כבוד המפקח לוי פרש מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן פסק דין. מכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 הועבר תיק זה לטיפולו עם מינויי לתפקיד, במהלך נובמבר 2012, לאחר פרישתו של כבוד המפקח לוי, ובתום הגשת סיכומי הצדדים בכתב.

ביום 20.11.12 ערכתי ביקור במקום, וביום 5.12.12 התקיים בלשכתי דיון במעמד באי כוח הצדדים. דיון זה זומן בעקבות בקשתו של ב"כ התובעת, עו"ד שינדלר, לשקול קביעת מועד דיון לשמיעה נוספת של העדים. במהלך דיון זה הבהיר ב"כ הנתבעים, עו"ד הומינר, כי מבחינתו אין צורך בשמיעה נוספת של העדים וכי עמדתו היא כי ניתן להכריע על יסוד החומר הקיים בתיק. בסיום הדיון ביקש עו"ד שינדלר לשקול את עמדתו וביום 12.12.12 הגיש הודעה ולפיה "מתכבדת התובעת להודיע כי אין לה התנגדות שינתן פס"ד בהתאם לחומר הנמצא בתיק".

בהתאם לאמור לעיל, הכרעתי זו ניתנת על יסוד החומר הקיים בתיק ובהסתמך על התרשמותי בביקור שערכתי במקום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תמצית העובדות וההליכים שקדמו למתן פסק הדין

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב שדרות לוי אשכול 2/26 בירושלים והידוע כגוש 30246 חלקה 6 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**"). הבית מורכב ממבנה לו שלוש כניסות, כאשר בכל כניסה 24 דירות ובסך הכל מונה הבית 72 דירות. דירותיהן של הצדדים להליך מצויות בכניסה ב' של הבית.
2. התובעת היא בעלת הזכויות בדירת קרקע הידועה כתת חלקה 26, ששטחה 97.40 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף 10/750 (להלן: "**דירת התובעת**"). הנתבעים הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 30 ודירתם מצויה בקומה הראשונה- מעל ביתה של התובעת. שטח ביתם של הנתבעים הוא 110 מ"ר וחלקם ברכוש המשותף- 11/750 (להלן: "**דירת הנתבעים**").
3. התביעה הוגשה במקור על ידי הגב' דינה אסתר שפירא ז"ל, אשר למרבה הצער נפטרה בעיצומם של הליכים אלו. בתה- יורשתה- הגב' שרה (ג'וי) שפירא המשיכה בהליכים כחליפתה. למען הנוחות, יכונה להלן שתיהן "**התובעת**".
4. לבית תקנון מוסכם מיום 20.2.94. בתקנון זה נקבע כי הבית המשותף הנו בית **מורכב**, כאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**" או "**החוק**").
- "בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק אנו קובעים בזאת כי הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחום כל כניסה (למעט הקרקע) יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה בלבד ולפיכך, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותה כניסה"** (סעיף 1 לתקנון המוסכם).
5. כמו כן נקבעו הוראות נוספות כגון כי "**הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל כניסה והשימוש בו הוא ייחודי לגבי אותה כניסה יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה**" (סעיף 2א לתקנון המוסכם) וכן כי "**שינויים ו/או תוספות בנייה לדירה, לא שינו, למרות הרחבת שטח רצפתה של הדירה, את שטח החלק ברכוש המשותף**" (סעיף 3ג לתקנון המוסכם).
6. הנתבע 1, במשותף עם שתי בעלות דירה נוספות בבית המשותף, אשר דירותיהן נמצאות אף הן בכניסה ב', הגישו בקשה לקבלת היתר בנייה ל- "תוספת מרפסות לא מקורות ל- 3 דירות", כששטח הבנייה הכולל המבוקש הוא 30.06 מ"ר. שטחה של כל מרפסת כ- 10 מ"ר. הבקשה להיתר בנייה אושרה ביום 26.3.07 (היתר מספר 58487 להלן: "**ההיתר**").



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

7. הנתבעים החלו בבניית מרפסת סוכה , בהתאם להיתר . עם תחילת הבנייה , פנתה התובעת בבקשה לקבלת צו מניעה זמני מבית משפט השלום בירושלים .
8. יצוין כי טרם קבלת היתר בנייה , היו בידי הנתבעים הסכמותיהם של בעלי דירות בכניסה ב ' בלבד . לאחר קבלת ההיתר ועם פתיחת ההליכים המשפטיים בנדון , פנו הנתבעים לקבל את הסכמותיהם של יתר בעלי הדירות בבית המשותף .
9. ביום 16.12.07 הורה בית משפט השלום (כבוד השופטת אנה שניידר) על מתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעים להמשיך בביצוע כל בנייה או תוספת בנייה בבית . ביום 23.12.07 הוגשה התביעה בהליך העיקרי וביום 11.5.08 הורתה כבוד השופטת שניידר על ביטול הצו הזמני .
10. התובעת, הגב' דינה שפירא ז"ל, ערערה על ההחלטה לביטול צו המניעה הזמני לבית המשפט המחוזי . ביום 14.8.08 הורתה כבוד השופטת חנה בן עמי על מתן סעד ארעי , ובהמשך הגישו הנתבעים בקשה לביטולו . כבוד השופט משה רביד , אשר דן בבקשת הביטול (בשא 3752/08), הורה על מתן סעד ארעי של צו מניעה זמני האוסר על הנתבעים להמשיך בבניית המרפסת וכן הורה על הסרת הפיגומים שהקימו . כמו כן קבע כי התיק יועבר למפקח על בתים משותפים , שהוא בעל הסמכות העניינית לדון בו .
11. התביעה התקבלה אצל המפקח על בתים משותפים ביום 24.9.08 . ביום 12.3.09 התקיים קדם משפט ולאחר מכן , בימים 10.11.10 , 2.3.11 , 29.5.11 נערכו דיוני הוכחות ונשמעו עדי הצדדים . סיכומי התובעת הוגשו ביום 10.7.11 וסיכומי הנתבעים ביום 9.10.11 .

תמצית טענות התובעת

21. התובעת טוענת כי ביום 16.12.07 החלו הנתבעים לבצע עבודות בנייה לשם בניית תוספת בצמוד לדירתם הנמצאת ברכוש המשותף .
31. לטענת התובעת פעולות הבנייה פוגעות **פגיעה קשה בזכויות הקנייניות** ועשויות להוביל ל **ירידת ערך דירתה** כתוצאה מהחשכת הדירה ומניעת כניסת אור ואוויר . כן נטען לפגיעה בתובעת עצמה שדירתה תהא חשוכה ללא כניסת אור ואוויר . כן טוענת התובעת **לפגיעה בחזית הבניין** שהינה רכוש המשותף . בסיכומיה טענה התובעת כי פעולות אלו מנוגדות להוראות סעיפים 17 ו-14 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"** או **"החוק"**), ולהוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי .



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

41. התובעת טוענת כי לעבודות הבנייה **לא ניתנה הסכמת** בעלי הדירות בבית, כנדרש על פי דין, כן נטען **לניצול זכויות הבנייה** השייכות לכלל דיירי הבניין "למרות התנגדות נמרצת של התובעת ושל חלק מהדיירים".

51. בסיכומיה הרחיבה התובעת בעניין זה והבהירה כי לשיטתה, היות ועסקינן במימוש זכויות בנייה השייכות לכלל בעלי דירות הבית, והן אינן חלק מהרכוש המשותף, יש צורך בקבלת הסכמה של **כל** בעלי הדירות. **לחלופין**, נטען כי ככל שיש צורך בהסכמת 3/4 מבעלי הדירות להם 2/3 מהרכוש המשותף, כאמור בסעיף 71ב לחוק המקרקעין, הרי שהסכמה זו צריכה להי נתן **באסיפה הכללית**. משלא ניתנה בדרך זו, אלא על דרך החתמה פרטנית של בעלי הדירות, הרי שלא ניתנה כדין ולפיכך, לשיטתה, לא קיימת ההסכמה הנדרשת בחוק המקרקעין לשם ביצוע עבודות ההרחבה. **לחלופי חילופין** טוענת התובעת, כי אף אם די בהחתמה פרטנית, הרי שבמקרה דנן לא עמד התובע בנטל ההוכחה המוטל עליו בכדי להוכיח את הסכמת בעלי הדירות כנדרש, שכן, בין היתר, החתימות לא הוגשו כדין והנתבעים לא הבהירו לשכנים כי בחתימתם הם מאבדים זכויות בנייה. יתרה מכך, בעלי הדירות לא העידו ואף לא הגישו תצהיר ערוך כדין. משכך, טוענת התובעת, הרי שאין ליתן כל משקל לראיות שהציגו הנתבעים בדבר הסכמת בעלי הדירות.

61. טענה נוספת שהעלתה התובעת היא כי לא ניתן לה יומה בפני הרשויות האמונות על התכנון והבנייה וכי במעשיהם או במחדליהם עושים הנתבעים "עושר ולא במשפט". נטען כי הנתבעים עשויים לגרום לה "ניזק בלתי הפיך" וכי יש במעשיהם משום הפרת חובה חקוקה של הוראות שונות בדיני הנזיקין, המקרקעין ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בסיכומיה אף הוסיפה התובעת וטענה כי מעשים אלו גורמים לה "מטרד ליחיד" כהגדרת המונח בסעיף 44 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

תמצית טענות הנתבעים

71. בכתב הגנתם טוענים הנתבעים כי הבניה הינה בהתאם להיתר בנייה שניתן להם כדין, וזאת לצורך הוספת מרפסת ולא חדרים, כנטען. הנתבעים מכחישים כי הבנייה פוגעת בזכויות קנייניות של התובעת וטוענים כי לא יהיה בה בכדי להפחית מערך דירתה. הנתבעים טוענים עוד כי לא הוכח שבניית המרפסת תגרם ום להחשכת דירת התובעת או למניעת כניסת אוויר אליה. כמו כן שוללים הנתבעים את הטענה כי בניית המרפסת גורמת לפגיעה כלשהי ברכוש המשותף, לרבות פגיעה בחזית הבניין.

81. לטענת הנתבעים, הם קיבלו את הסכמתם של למעלה מ 90% מבעלי הדירות ועל כן ממילא יש בידם את הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלהם 2/3 מהרכוש המשותף, כנדרש על פי חוק המקרקעין לביצוע ההרחבה. בסיכומיהם הרחיבו הנתבעים בעניין זה וטענו כי כלל לא נדרש בדין שההסכמה תינתן במסגרת כינוס האסיפה הכללית. נטען כי הסכמת בעלי הדירות ניתנה להם לאחר "שהובהר לכל דייר ודייר מהות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

חתימתו ומה כרוך בכך, ובין היתר הובהר לכל שכן ושכן כי בחתימתו על ההסכמה הוא בפירוש מוותר על חלקים מסוימים בחלקו ברכוש המשותף".

91. ממילא, כך טוענים הנתבעים, בניית מרפסת זיזית תלויה כלל אינה פוגעת בזכויות הבנייה של בעלי דירות הבית המשותף וזאת מכוח תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים) (תשנ"ב-1992. כך נטען, כי משום שאין בבנייה משום נטילת זכויות בנייה, כלל לא נדרש היה להסביר ליתר בעלי הדירות כי בהסכמתם הם מאבדים זכויות בנייה.

02. הנתבעים טוענים עוד כי דין התביעה להידחות, מאחר וכתב התביעה הוגש בחוסר תום לב ולאחר הסכמתה של התובעת עצמה לביצוע פעולות הבנייה, אשר בהסתמך עליה השקיעו כספים רבים. לטענתם, התובעת נתנה ביום 14.11.07 את הסכמתה לבניית המרפסת ובתמורה התחייבו הנתבעים לבנות חדר נוסף בדירת התובעת, מתחת למרפסת אותה מבקשים הנתבעים לבנות, וזאת ללא קבלת תמורה מהתובעת. הנתבעים טוענים כי בחזרתה מהסכמתה גרמה להם התובעת נזקים קשים.

12. בהתבסס על סעיף 71 (בג) לחוק המקרקעין הקובע כי: "מעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין" נטען עוד כי התובעת עצמה הרחיבה דירתה על חשבון רכוש משותף מבלי שקיבלה על כך הסכמה ממי מהשכנים וללא היתר בניה כדין. על כן, לטענתם, היא מנועה כעת מלהעלות טענות נגד הרחבה של שכן אחר "למרות שאינה דומה אחת לאחת להרחבה שהיא ביצעה". הנתבעים מכוונים בזאת לחלל ליד המעלית, אותו לטענתם סגרה התובעת ועשתה בו שימוש.

דיון והכרעה

22. בראשית הדברים אבהיר כי טענות הנוגעות לזכות הגישה של התובעת לרשו יות האמונות על התכנון והבנייה, עשיית עושר ולא במשפט, טענות מתחום דיני הניזקין כגון נזקים שנגרמו לה, מטרד, טענות בדבר הפרת חובה חקוקה – כל אלה אינן בגדר הסמכויות הנתונות למפקח על רישום מקרקעין. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק, הקובע:

72. "סמכות להכריע בסכסוכים

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59, 58, או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב - 1982 יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
- (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

32. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 וקבעו, כי אין להרחיב את פירושו (ראה למשל: ד"נ 20/73 שמוע נ' סדובסקי, פ"ד כח (1) 730, עמ' 733 מפי ממלא מקום הנשיא (כתוארו דאז) זוסמן).

42. לפיכך, טענות אלו לא ידונו במסגרת פסק דין זה. מובן כי לתובעת, כמו גם לנתבעים, שמורה הזכות להעלות טענות אלו בערכאות המוסמכות לכך.

52. ולגופו של עניין- שלוש מחלוקות עיקריות התגלעו בין הצדדים ובהן יש להכריע בגדרי פסק דין זה:

האחת, האם לרשות הנתבעים ההסכמה הנדרשת בחוק לצורך הרחבת דירתם על חשבון הרכוש המשותף לשם ביצוע הבנייה?

השנייה, האם נפגעו זכויות הבנייה היחסיות של התובעת להרחבה?

השלישית, האם מימוש היתר הבנייה ייפגע פגיעה מהותית בזכויות התובעת?

62. יוער כבר עתה, כי אף אם יימצא כי יש בידי הנתבעים את ההסכמה הנדרשת על פי סעיף 71ב אין בכך די, ככל שיוכח כי יש בבנייה בכדי לפגוע בזכויות הבנייה היחסיות של התובעת. במקרה כזה, לא ניתן יהיה לבצע את הבנייה ללא הסכמתה המפורשת. בדומה, הרי ככל שיימצא כי הבנייה פוגעת בתובעת פגיעה מהותית, הרי שאף אם קיימת ההסכמה הנדרשת, ניתן יהא להורות על ביטול, ולה, שינויה או התנאתה בתנאים, כקבוע בחוק.

72. נפנה להכרעה בכל אחת ממחלוקות אלו, ראשון- ראשון ואחרון- אחרון.

האם בידי הנתבעים ההסכמה הנדרשת בחוק לצורך ביצוע הבנייה?

82. ראשית אעמוד על טיב ההסכמה הנדרשת בדין וכן אדון בשאלה האם עליה להינתן באסיפה כללית או שדי בהחתמה פרטנית של בעלי הדירות. לאחר מכן ייבחנו נסיבות המקרה שלפנינו.

92. הכלל לפיו כל שינוי ברכוש המשותף דורש את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיפים 62(א) סיפה ("אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" ו-12(ב) לתקנון המ צוי ("בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות...").

03. התובעת טענה בסיכומיה כי "אין בהחלטה שנתקבלה לפי סעיף 71ב לחוק כדי לפטור את בעל הדירה מהחובה לקבל הסכמה מיוחדת מהדייר שנפגע באורח מיוחד מהבנייה". בטענתה זו נסמכת התובעת על



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

סעיף 2 לתקנון המצוי הקובע כי : " בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו , אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות . לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה ". כן מפנה התובעת לסעיף 14 לחוק הקובע : " הגבלת זכויות - בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר".

13. סעיף 71ב לחוק קובע כדלהלן :

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד ל דירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוים ימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית , לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה , וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה , ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי , רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

23. סעיף 71ג לחוק המקרקעין קובע :

71ג. הגשת תביעה למפקח
 (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.
 (ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 (ג) הוראות סימן ד' לפרק זה יחולו על הדיון בפני המפקח, בשינויים המחוייבים.
 (ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 (ה) אין בפניה למפקח, כשלעצמה, בכדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת.

33. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק – " הגדלה של שטח דיור קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

43. הגדרת המונח "הרחבה" בסעיף 71ב היא הגדרה רחבה :
- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש"** (ר': א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות דיני מקרקעין**, חלק ג', 222, ההדגשה לא במקור; ר' גם הפסיקה המובאת שם).
53. לפיכך, כבר נקבע בפסיקה כי גם בניית מרפסת "תלויה" מהווה "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק (ראה: ע"א (ירושלים) 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01. להלן: **"פרשת אזרד"**).
63. בדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) (התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114) נכתב:
- "מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, במטרה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים של משפחות רבות בדרך של הרחבת דירות קיימות או לבעיית צפיפות אוכלוסין השכיחה באזורים מסוימים בארץ, בדרך של בניה על הרכוש המשותף. על פי המוצע בסעיף 71ב יהיו רשאים רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, להחליט על שינויים ברכוש המשותף, אם מטרת השינוי היא הרחבת דירה קיימת אחת, או יותר, בבית המשותף. כיום, על פי הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החלטה זו טעונה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. דרישה זו מהווה מכשול מהותי ומוצע לשנותה. יחד עם זאת מוצע לקבוע במפורש מנגנון לפיצוי בעל דירה שנפגע באופן מהותי בדרך של תשלומי איזון.**
73. אם כן, במסגרת תיקון 18 לחוק נקבע **חריג**, המתייחס באופן פרטני לשינוי ברכוש המשותף **על דרך של הצמדתו לדירה פלונית**, כאשר לגבי שינוי או פגיעה במובן זה ברכוש המשותף, דורש המחוקק הסכמה ברוב מופחת מזה הנדרש לצורך הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, ככלל. יתרה מכך, המחוקק אף קובע הסדרים פרטניים באשר לדייר שנפגע מקבלת ההחלטה "פגיעה מהותית" - וזאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים, וכן על תשלום דמי איזון לנפגע. לפיכך, ברי, כי אין הכרח בהסכמתו של הנפגע לבנייה, שכן אם אכן נכונה הטענה, יורקנו מתוכן הסדרים אלו.
83. לפיכך, אין לי אלא לדחות את טענת התובעת לצורך **בהסכמת כל הדיירים** לבנייה דנא, או לצורך בהסכמתה המפורשת.
93. באשר לאופן מתן ההסכמה הנדרשת במסגרת סעיף 71ב לחוק, נחלקו בתי המשפט בסוגיה. אני סבורה, בדומה לעמדות דומות שהובעו בפסיקה, כי אין צורך ש ההסכמה תינתן במסגרת האסיפה הכללית, וכל



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

עוד ברור מתכנה כי בעל הדירה ויתר על זכותו הקניינית והסכים לניצול אחוזי הבניה, יכולה הסכמה זו להינתן בכל דרך אחרת.

04. בפרשת אזרד עמד בית המשפט המחוזי בירושלים על הוראת סעיף 71 וקבע:

"כבר בשלב זה יאמר, כי בסעיף 71 לחוק כלל לא נזכרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. עניין זה בולט לרקע הוראות אחרות שבחוק. בסעיף 159 לחוק הוסדר נושא התקנת מעלית. בסעיף זה נקבע שבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות רשאים להחליט באסיפה כללית על התקנת המעלית (בכפוף לקיום תנאים מסויימים). והנה, בסעיף 71 לא נזכרת אסיפה כללית ודובר אך בהחלטה. מכאן שהמחוקק לא דרש כינוס אסיפה. איננו רואים מדוע החלטה כאמור לא יכולה להתקבל גם בכתב, כאשר בעלי הדירות רשמים את עמדתם בדרך של הסכמה או התנגדות...." (ההדגשות לא במקור).

14. דברים דומים נקבעו גם בת"א (שלום-י-ם) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי, תק-של 1596, 1595, (3)2005 מפיו של כבוד השופט נעם סולברג:

"סעיף 71 לחוק איננו מזכיר - ולו ברמז - את האסיפה הכללית (להבדיל, למשל, מסעיף 159 לחוק); אין טעם ולא תכלית לערום קשיים בפני מי שמבקש לבנות ברכוש המשותף לצורך הרחבת דירתו, כשמגמת החקיקה הינה להקל, ולא להכביד עליו; העיקר בסעיף 71 הנ"ל הינו ההסכמה; המהות, ולא הפרוצדורה. הכללים המורכבים לגבי האסיפה הכללית, כינוסה ותהליך קבלת ההחלטות, עלולים לסכל קבלת החלטה על שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה"

(ראה גם: ת"א (שלום-י-ם) 14565/06 משה שמחוביץ ואח' נ' שפרה גיל ואח' (פורסם באתר נבו); בש"א (שלום-י-ם) 8251/07, שטיין נ' קוצר (פורסם באתר נבו)).

24. בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי, עמ' 215 מציין המלומד אריה אייזנשטיין כך:

"יצוין, כי רק בסעיף 159 נאמר כי החלטה על התקנת מעלית צריכה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית. בסעיפים אחרים בחוק המקרקעין שבהן נדרשת הסכמה או החלטה של רוב מסוים, לא נאמר בהם כי ההחלטה צריכה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית. לדוגמא, החלפת ספק גז על פי סעיף 259 (ב); שיקום בית משותף שנהרס על פי סעיף 60; עריכת תקנון מוסכם; והרחבת דיור על פי סעיף 71(א).

בכל העניינים האלה ההחלטה יכולה להתקבל הן בדרך של הסכמה בכתב והן בדרך של החלטה במסגרת אסיפה כללית. אין שום הגיון ליצור הבחנה בדרך קבלת ההחלטות בין עניינים שונים הטעונים החלטה או הסכמת רוב. די לו למחוקק, אם הוכח שהרוב הביע הסכמתו או נתן החלטתו באופן חוקי בין במסמך בכתב ובין באסיפה כללית...."

34. נקבע עוד, כי הסכמה זו יכולה להינתן בכל עת, אף לאחר שההרחבה כבר בוצעה, ולא יהא מקום למתן צו האוסר שימוש בהרחבה (מהפן הקנייני כמובן), אם יוכיח בעל הדירה כי בי דיו ההסכמות הנדרשות. יפים לעניין זה דברי פרופ' דויטש (מ. דויטש, קניין, 699-698), שקבע כדלקמן:



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

...בעניין שנדון בבית משפט השלום בעניין שטנג נפסק , כי תיקון מס' 18 לחוק, אין בכוחו להכשיר פעולה שנעשתה שלא כדין בעבר, באמצעות קבלת החלטה עתה ברוב המיוחד, לפי התיקון. עם זאת נקבע, כי אין טעם לחייב עתה בהשבת מצב לקדמות, כאשר ברור שקיים רוב בעד ההצמדה לפי תיקון 18 לחוק...אולם באשר לצו מניעה, בהיותו חוזה פני עתיד בלבד, אין אכן הצדקה לגרום להריסה מיותרת, כאשר בעלי רוב החלקים החליטו עתה להכשיר את הפעולה, והיא ניתנת, אם כן לבצוע חוזר. הריסה כאמור גם תעמוד בניגוד לתורה הכלכלית- תועלתית. הדין בסוגיה זו מקביל לדין החל כאשר מתקבלת החלטה בדיעבד של האסיפה הכללית, המכשירה פעולה שפוגעת ברכוש המשותף, בעוד שסעיף 2(א) לתקנון המצוי דורש כי החלטה המכשירה פגיעה כאמור תתקבל מראש...בעניין שטנג, ההחלטה נתקבלה לאחר תיקון מס' 18, אף שהפעולות הפיסיות כבר נעשו בעבר. במובן זה אין מניעה אכן לומר כי ההחלטה כיום, לאחר התיקון, מכשירה את המשך הקיום בעתיד של הבניה...". (השווה גם לאמור בפסק הדין בע"א 93/84 קדמי נ' קוין, פד"י, מ(1), 724, וכן לדברי א. אייזנשטיין, שם, 229).

ודוק: דברים אלו יפים מקל וחומר, במקרה בו טרם בוצעה הבניה, ובעת הדיון ב פני המפקח מוגשות ההסכמות להרחבה.

44. על כן, גם במקרה דנן, עלינו לבחון האם הוצגו ההסכמות הנדרשות כיום – היינו, בעת ההכרעה בבקשה למתן צו עשה וצו מניעה קבוע.

54. נפנה, אפוא, לבחינת הנסיבות הפרטניות.

64. הנתבע 1 הציג רשימה של בעלי הדירות בבית המשותף וחתומותיהם על הסכמה לבניית הסוכה (נ/7). נוסח הסכמה עליו התבקשו לחתום הנו כדלהלן:

"הסכמת דיירי רוחב לוי אשכול 2 ירושלים כניסות א' ב' ג' גוש 30246 חלקה 6 לבניית מרפסת סוכה בבית משפחת אריה מכניסה ב'

אנו/י הח"מ בעל/י הדירות בכניסות א' ב' ו-ג' ברחוב לוי אשכול 2 בירושלים והידועות כגוש 30246 חלקה 6, מסכימים בזאת להרחבת דירת מר אריה יעקב באופן של בניית מרפסת סוכה בקיר הצמוד לרחוב מדבר סיני בדירה מס' 30 בכניסה ב' השייכת למר יעקב אריה, והכל עפ"י היתר בנייה מעיריית ירושלים המצוי בידו, היתר מתאריך ספטמבר 2007 (היתר מס' 58487).

המרפסת והקיר הצמוד לה יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו למשפחת אריה יעקב"

74. אציין כבר עתה כי הצדדים להליך לא הפנו לתקנון המוסכם של הבית ולא העלו טענות הנוגעות להשלכה אפשרית של היות הבית המשותף בית מורכב על נסיבות עניינינו. למעלה מן הצורך אציין כי לדידי, ומבלי לקבוע בכך מסמרות, ייתכן ויש בהוראה בתקנון המוסכם לפיה מוצמד הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה לדירות אותה כניסה- בכדי להוביל למסקנה כי ההסכמה הנדרשת בעניינינו היא הסכמת בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד. אולם, מאחר וטענה זו לא הועלתה בפני, וממילא הנתבעים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

טענו להסכמת הרוב הנדרש ביחס לכל בעלי הדירות בכל כניסות הבית המשותף , לא מצאתי צורך להכריע בכך.

84. ממסמך נ/7, לרבות הסכמות של מוטבי הערות אזהרה (למשל- דירה 3), ושל יורשים (כמו דירה 4-נ/9, דירה 15-נ/14, דירה 17-נ/15) ובצירוף הסכמות בעלים אשר ניתנו בפקס (דירה 39-נ/20, דירה 44-נ/22, דירה 69-נ/25), והסכמות של מיופי כוח הבעלים (למשל- דירה 41-נ/21, דירה 62-נ/23, דירה 71-נ/26), **עולה כי לכל הפחות 55/72 בעלי דירות** נתנו הסכמתם לבנייה המבוקשת. דהיינו, למצער, קיימות הסכמות של 76% מבעלי הדירות להם למעלה מ- 2/3 מהרכוש המשותף (540/750). יובהר כי מדובר בחישוב שנעשה על הצד הזהיר ביותר, ולא נכללות בו דירות בהן הוצגו חתימות של רק חלק מהבעלים, דירות שההסכמות הנטענות לגביהן לא היו מגובות במסמכים, ודירות בהן מהות החתימות בשם בעלי הדירות הרשומים לא ברורה. בסופו של דבר, בחישוב זהיר זה לא נכללו הסכמות לגבי תתי חלקות 1,2,4,14,16,19,20,26,28,36,43,53,56,59,60,61,68.

94. התובעת טענה כנגד תקפותן של חלק מהחתימות- לגבי תתי חלקה 18, נטען כי צורף צו ירושה אך ללא חתימת יורש ולגבי תתי חלקה 68 נטען כי לא צורף כלל אישור פטירת מי מהבעלים. כן נטען כי לגבי תתי חלקה 61, שבעליה הם ציון ומלכה הראתי, הרי שמדובר בזוג גרוש וניתנה חתימת הגבר בלבד.

05. ביחס לתתי חלקה 18- לפי נסח הרישום, זכויות הבעלות בה רשומות על שם "גידאיאן יוחנן וגידאיאן ושווקט" בחלקים שווים. הוצג בפני צו ירושה (נ/16) של המונח "גידאיאן יוחנן" ולפיו "גידנאן שוקט ת.ז. 012974556" היא היורשת (יצוין כי על אף היעדר הזהות בי ן שם הרישום בנסח לבין שם היורשת, הרי שמספר תעודת הזהות זהה ועל כן נראה כי המדובר בטעות סופר בלבד). בהתאם לרישום נ/7, הרי שניתנה חתימתה של גידאיאן ושווקט, ועל כן, בהיותה היורשת של גידאיאן יוחנן, די בהסכמתה.

15. לגבי תתי חלקה 68- לפי נסח הרישום, הדירה בבעלות ברוך מנחם וברוך טילדה. נספח נ/24 מהווה אישור בפקס של הגב' ברוך טילדה. נעדרת חתימתו של מר מנחם ברוך, כאשר במסמך נ/7 מצוין ברובריקה הנוגעת לחלקה 68 "יש לי פקס של טילדה בעלה נפטר". אכן, לא הוצג כל אישור כי הבעל נפטר או צו ירושה כלשהו המעיד כי הגב' טילדה היא יורשתו היחידה.

25. באשר לתתי חלקה 61- הרי שבעדותו הסכים בן עזרא כי הגב' מלכה הראתי לא חתמה וכי ניתנה רק חתימת הבעל (ראה פרוטוקול מיום 29.5.11, עמ' 3, שורה 38).

35. כפי שציינתי לעיל, בחישוב הזהיר שפורט לעיל לא נכללו הסכמות לגבי דירות 68 ו-61, ויחד עם זאת, עדיין עומדות לזכות הנתבעים הסכמות לפחות 55/72 דירות, המהוות 76%, להם למעלה מ-2/3 מהרכוש המשותף. רוב זה הוא מעבר לרוב הנדרש על פי דין.

45. מעבר לכך, התובעת לא טענה בפה מלא לאי תקפותן או היעדר נפקותן של חתימות אחרות שניתנו בפקס, חתימות של בעלי הערות האזהרה, חתימות של יורשים ומיופי כוח. משעה שהוצג המסמך המעיד על החתימות והנתבע 1 הבהיר בעדותו כי ההסכמות כוללות גם הסכמות בעלי הערות אזהרה,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

יורשים ומיופי כוח, ואף צירף כאמור לעיל מסמכים לתמיכה בטענתו זו, הנטל להפריך את ההסכמה הועבר לכתפי התובעת. התובעת לא הציגה ולו בדל ראיה לטענתה, כי ייתכן ומדובר בחתימות בלתי מהימנות. התובעת לא טענה בפה מלא, מעבר לטענותיה הפרטניות לגבי תת חלקות 18,68,61 לעיל, כי החותמים אינם בעלי הזכויות שחתימתם נדרשת ולא הלינה על היות החותמים בעלי הזכויות הרלוונטיים להחתמה. ממילא, היא לא השמיעה מטעמה ולו בעל דירה אחד אשר טען כי החתימה הנחזית להיות חתימתו איננה כזו.

55. מכאן כי הוכח בפני כי קיימות הסכמות של לפחות 76% מבעלי הדירות להם למעלה מ- 2/3 מהרכוש המשותף.

65. השאלה בה יש להכריע בנסיבות אלו, היא האם הסכמת הרוב הדרוש על פי החוק ניתנה לאחר שהיה ברור לבעל הדירה אשר נתן הסכמתו כי הוא ויתר על זכותו הקניינית.

75. הנתבע 1 העיד כי עבר מדירה לדירה יחד עם אורן יצחקוב (בכניסה א' ו-ב') וברוך בן-עזרא (בכניסה ג'), שהנם בעלי דירות בבית (פרוטוקול מיום 2.3.11, עמ' 10 שורות 10-11). לגבי מהות ההסבר שניתן לבעלי הדירות טרם קבלת הסכמתם, העיד הנתבע 1 כך: "אני אמרתי לדיירים שאני רוצה לבנות מרפסת סוכה ושהם צריכים לוותר לי חלק מהרכוש המשותף. הצגתי בפניהם את נ/7 והם חתמו לי. מי שלא הבין הסברתי לו" (ראה שם, שורות 17-20). "לא דיברתי עם הדיירים על לקיחת זכויות בנייה" (שם, שורה 20).

85. הנתבע 1 טען כי לקח עמו את אורן יצחקוב מאחר וסבר שהוא מכהן ב נציגות הבית, דבר שהתברר בהמשך כמשגה. כך או כך, אינני רואה חשיבות רבה בכך שליווה את הנתבע 1, לצורך ביצוע ההחתמות, גורם המכהן בנציגות או כל בעל דירה אחר בבית. "לליווי" עשויה להיות משמעות ראייתית, לצורך הוכחת ההסבר שניתן לדיירים אשר נתנו הסכמתם טרם חתימתם ובאשר למידת הבנתם את מהות החתימה. המשקל שניתן לעדות זו, כל עוד מדובר בעד שהוא גורם אובייקטיבי, זהה- בין אם הוא מכהן בנציגות ובין אם לאו. ממילא, במקרה דנן לא הרחיב יצחקוב בעדותו בכל הנוגע למהות ההסבר שניתן לבעלי הדירות בפועל.

95. ברוך בן עזרא (להלן: "בן עזרא") העיד כי הוא חבר בוועד הבית של כניסה ג' וכי ליווה את הנתבע להחתמת בעלי הדירות בכניסה זו. בעדותו ציין כי הבקשה לבניית מרפסת הוצגה לדיירים וכי ניתן להם הסבר שנוגע לכך שהסכמתם משמעה ויתור על חלק מהרכוש המשותף: "אני הגעתי לדיירים בבית יחד עם הנתבע מס' 1 והצגנו בפניהם את הבקשה של הנתבעים לבנות מרפסת. דובר עם הדיירים על קבלת חתימות לצורך הרישיון מהעיר ייה ושיוותרו על החלק שלהם ברכוש המשותף" (ראה פרוטוקול מיום 29.5.11, עמ' 3 שורות 17-21).

06. הנה כי כן, התובע מצדו הביא ראיות משכנעות כי הסכמת בעלי הדירות ניתנה מתוך הבנה כי משמעה ויתור על חלקים ברכוש המשותף; הדברים עולים הן מנוסחו של נ/7 המתייחס בסיפא במפורש לויתור



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

על חלקים ברכוש המשותף, והן מעדויות הנתבע ובן עזרא באשר להסברים שניתנו לבעלי הדירות בנושא זה- עדויות שלא הופרכו.

16. במצב דברים זה, עבר הנטל לתובעת להראות כי בעלי הדירות שנתנו הסכמתם, או חלקם, לא הבינו את משמעות הדרישה ואת השלכותיה של הסכמתם. אולם, גם בעניין זה לא הביאה התובעת עדות כלשהי או ראיה מפריכה אחרת שיש בה כדי ללמד על היעדר הבנה מספיקה בדבר מהות החתימה, או על אי מהימנותן של החתימות - משכך, יש לזקוף זאת כראיה לחובתה [ראה: ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד, ל"ה(1), 736, ע"א 2275/96, לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז (2), 605, ע"א 27/91, קבלו נ' שמעון עבודות מתכת, פ"ד מט(1), 450].

26. הנה כי כן, מצאתי כי אכן יש בידי הנתבעים את ההסכמה הנדרשת בחוק- הן כמותית והן מהותית.

האם נפגעו זכויות הבניה היחסיות של התובעת להרחבה?

36. בכל הנוגע לאחוזי הבניה, הרי שהנתבע 1 אישר כאמור כי לא דיבר כלל עם הדיירים לגבי ויתור על זכויות הבניה. לשיטתו, הרי שאין בכך צורך שכן הבקשה לבניית המרפסות אינה גוזלת מזכויות הבניה של יתר הדיירים.

46. טענה זו מבססים הנתבעים על הוראת תקנה 2 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים) (תיקון) התשס"ח-2008 (להלן: "תקנות חישוב שטחים") מיום 25.3.08, ואשר פורסמה ביום 30.4.08, הקובעת כי:

2. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן- יום התחילה).

(ב) בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט ל תיתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנה זו- גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה:

(1). גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין.

(2)עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבניה;

(3) גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו;

56. היתר הבניה ניתן לנתבע 1 לפני יום התחילה ולפיקד חלות במקרה דנן הוראות התיקון לעיל. המרפסת אותה מבקש הנתבע לבנות היא מרפסת ב שטח של כ-10 מ"ר ועל כן- אינה נמנית במניין השטח המותר לבניה. יצוין כי אמנם על פי סיפת הסעיף, ככל ששטחן הכולל של הגזוזטרות בבניין עולה על 12 מ"ר



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

כפול מספר הדירות בבניין, גם מרפסת שגודלה קטן מ-14 מ"ר תימנה כשטח המותר לבנייה, אולם גם במקרה הנדון לא טענה התובעת כי מתקיימת סיפת הסעיף. ממילא, התובעת לא הצגה ראיות להפרכת הטענה (וזאת על אף שכבר בכתב ההגנה נטען כי על פי תקנות חישוב שטחים מרפסת פתוחה אינה נכללת באחוזי הבניה המותרים בבניין ולפיכך אין הנתבעים מנצלים אחוזי בניה על חשבון יתר בעלי הדירות).

66. יובהר כי אמנם מימוש בניית שלוש המרפסות שהן נושא היתר הבנייה הורגות מאותם 14 מ"ר האמורים בסעיף 2(ב)(1) לתקנות חישוב שטחים, אולם, התובעת לא הלינה על בניית שתי המרפסות הנוספות ואף כלל לא ברור אם בסופו של דבר ההיתר בגינן מומש. מכל מקום, כאמור, התובעת לא טענה בעניין זה דבר.

76. לפיכך, הרי שמצאתי כי לא נפגעו זכויות הבנייה היחסיות של התובעת להרחבה.

86. אולם, בכך לא סגי שכן התובעת טוענת עוד כי מימוש הבנייה יגרום לפגיעה מהותית בזכויותיה.

האם מימוש היתר הבנייה ייפגע פגיעה מהותית בזכויות התובעת?

96. מהי, אם כן, פגיעה מהותית, בה דן סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין? המלומד א. אייזנשטיין מפרש זאת כך:

"פגיעה מהותית" - בהקשר לסעיף 71ג(ד) הנ"ל, הינה פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף, מטרד מתמשך וכיו"ב... (ראה: א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 218).

07. כב' המפקח (בדימוס) פנחס לוי, בתיק מספר 127/02 פלוטקין נ' קויפמן (פורסם ב"נבו"), דן בהרחבה בפרשנות המונח "פגיעה מהותית" בסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין וקבע שם, בין היתר, כך:

"פגיעה מהותית" - לדעתי, יש לפרשה כך שלא תאפשר לבעל דירה את המשך המגורים בדירתו, ולא רק פגיעה בכמות ו/או במכסת האוויר, האור ו/או הנוף, שכן כל בניה מכל מין וסוג שהוא יש בה מידה מסוימת של שינוי בצורת החלל ו/או בצורת הנוף והפועל היוצא ממנו הוא פגיעה באוויר, באור וכיו"ב...

... לנו נראה כי המבחן ו/או הפרשנות של "פגיעה מהותית" לעניין הרחבת דירה, צריך להיות כך- שלא יתאפשרו מעבר ו/או גישה חופשיים אל הדירה הנפגעת ו/או קיום של חיים סדירים ותקינים בה, עקב תוספת הבניה ו/או הרחבת הדירה..."

17. בע"א 133/97, יוסוביץ נ' חי ואח' (לא פורסם - להלן: "עניין יוסוביץ"), נדון המונח "פגיעה מהותית", בהקשר של בניית מעלית, כאמור בסעיף 59א(2) לחוק המקרקעין. נקבע שם כך:

"...הגב' חי רכשה את דירתה כאשר היו בה אוורור טבעי ותאורה טבעית, באותן מגבלות פיזיות שבהן נבנתה הדירה מלכתחילה. אולם ברור שהדירה נבנתה ונרכשה כדירה שיש בה תאורה ואוורור טבעיים, גם אם איכותם לא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הייתה מושלמת. לא בכדי עמדה המפקחת על הפגיעה המשמעותית ביותר
הן במקור האור והן במקור האוויר לדירה, כתוצאה מעבודות ההתקנה של
המעלית, ואנו תמימי דעים אתה לגבי חומרת הפגיעה באיכות החיים בדירה
(גם אם לא עשתה שימוש במילים אלה דווקא). אנו סבורים כי הירידה
הצפויה באיכות החיים בדירה (בהיבט של אוורור ותאורה טבעיים) מהווה
"פגיעה מהותית" בדירתה של חי, ועל-כן לא התמלאו שני התנאים
הקבועים בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין לשם קבלת החלטה באסיפה
הכללית על התקנת מעלית..."

27. יחד עם זאת, בפסק דין זה נקבע כי "מהות הפגיעה ועוצמתה זהו עניין למפקחת לדון בו".
37. נפנה לבחינת נסיבות המקרה דנן. טענות התובעת לפגיעה מהותית בזכויותיה נשענות על שלושה אדנים מרכזיים – ירידת ערך דירתה, הסתרת הנוף ומניעת כניסת אור ואוויר לדירה, ופגיעה בחזית הבניין.
47. בכל הנוגע לטענה בדבר ירידת ערך, הרי שהיא נטענה בעלמא ומבלי שהביאה התובעת לכך כל ראיה כגון חוות דעת מומחה מקצועית או אחרת. לפיכך, ומשלא הוכחה אין לי אלא לדחותה.
57. באשר לפגיעה בחזית הבניין, הרי שגם אם טענה זו תוכח, הרי שלדידי אין לראות בכך פגיעה שעיקרה הוא קנייני (אלא אם כן מוכח כי היא מובילה לירידת ערך הדירה, דבר שלא הוכח בפני, כאמור), אלא פגיעה שליבתה בדיני התכנון והבניה. תחום זה אינו בסמכותי. על המערערת היה להעלות טיעוניה אלו בפני רשויות התכנון המוסמכות בעת שדנו בבקשה למתן היתר הבניה או בערכאות הערעור על ההחלטה בעניין מתן ההיתר. גם בהחלטת כבוד הנשיאה מוסיה ארד בעת "מ (י-ם) 581/05, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים נ' ועדת הערר המחוזית מחוז ירושלים (פורסם ב"תקדין")", עליה ביקשה התובעת להסתמך, נאמר כי על מנת ליתן פתרון לבעיית המרפסות הפוגעות בחזיתות הבתים מן הראוי למצוא פיתרון של "תכנון כולל" לשכונת רמת אשכול.
67. ביחס לטענות הנוגעות לפגיעה בנוף ולמניעת כניסת אור ואוויר, הרי שכאמור, בנסיבות מסוימות הכירה הפסיקה ביכולתה של פגיעה מטעמים אלו להיחשב כ"פגיעה מהותית". אם כן, הרי שיש לבחון את טיבן, ולהכריע לפי נסיבות המקרה אם יש בהן ממש.
77. ביום 11.3.08, במסגרת הדיון בבקשת התובעת לקבלת צו מניעה זמני, העידה התובעת כך: "אני אמרתי לו שאני לא רוצה את המרפסת. אני גרה למטה וחשוד שם. אמרתי לו מיד שאני לא רוצה שיחסמו לי את האור והאוויר והשמש. הייתי נגד זה. לא רציתי שהדירה תיראה כמו מרתף" (פרוטוקול דיון מיום 11.3.08, עמ' 3 שורות 15-16).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

87. בחקירתה, אמרה בתה של התובעת כך- "אני מתנגדת שהנתבעים יבנו מרפסת מעל דירתי , שכן הדירה שלי מאוד חשובה , תמיד הייתה חשובה ואם הנתבעים יבנו מרפסת מעל הס לון שלי זה יחשיך את הדירה עוד יותר וגם אוויר ייכנס אליה פחות" (פרוטוקול דיון מיום 2.3.11, שורות 15-17).

97. בתמיכה לטענות אלו הציגה התובעת תמונות (ת/1) בהן נראים פיגומי המרפסת אותה מבקשים הנתבעים לבנות. מסיכומי התובעת אף עולה כי על תמונות אלו היא מבקשת להסתמך בטענתה העובדתית בדבר הפגיעה המהותית " שכן לדבריה "תמונות הפיגומים שהניחו הנתבעים לצורך ביצוע עבודות הבנייה מדברות בעד עצמן ומעידות על הפגיעה שנגרמת למבקשת כתוצאה מהבנייה וזאת עוד לפני שיצקו משהו לדורות".

08. בתמונות אלו נראית דירת הקרקע של התובעת כשמעליה הכנות לבניית המרפסת. ייתכן ויש בתמונות אלו בכדי להעיד על חסימת אור ואוויר במידת מה , אולם אין בהן כדי להראות כי חסימה זו , ככל שקיימת, הנה בעוצמה ניכרת. מטבע הדברים, כמעט כל בניה שהיא בבית משותף עשויה לגרום אי נוחות או פגיעה מה בעל דירה זה או אחר , וזהו חלק טבעי ממרקם החיים בבית המשותף. לא ייתכן כי כל פגיעה טבעית כזו תוכל להוביל לסטייה מהכלל כי די בהסכמת הרוב הדרוש בסעיף 71ב ולהפעלת סמכויות המפקח הקבועות בסעיף 71ג(ד). לא בכדי קבע המחוקק כי רק "פגיעה מהותית" בזכותו של בעל דירה תקנה למפקח את היכולת להפעיל סמכויותיו אלו.

18. מלבד לתמונות לעיל לא הוצגה בפני כל ראייה המוכיחה את הפגיעה הנטענת וממילא את עוצמתה . כך למשל, התובעת לא הציגה בפני חוות דעת מומחה להוכחת טענותיה או לא העידה כל גורם שהוא בנושא .

28. גם בביקור שערכתי במקום , לא התרשמתי כי בבניית המרפסת המבוקשת יהיה בכדי לפגוע בכניסת האור והאוויר לדירת התובעת באופן מהותי . אציין כי במועד הביקור לא נכחה התובעת עצמה, ומטעם זה לא התאפשרה הכניסה לדירתה.

38. משכך ובהיעדר ראיות, הרי שלא הוכחה הסתרת אור ופגיעה בזרימת האוויר במידה הנדרשת . על כן, לא שוכנעתי כי בבניית המרפסת המבוקשת יש משום פגיעה מהותית בתובעת.

48. משמצאתי כי דין התביעה להידחות מהטעמים המנויים לעיל , לא ראיתי צורך לדון בטענות נוספות של הנתבעים כגון טענה להרחבה דומה שביצעה הנתבעת עצמה , או הטענה כי התובעת חזרה בה מהסכמתה לאחר שהנתבעים כבר הסתמכו עליה ושינו מצבם לרעה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

סוף דבר,

58. התביעה נדחית.

68. צו המניעה הזמני- מבוטל.

78. התובעת תשא בהוצאות הנתבעים ובשכר טרחת עורך דינם בסך כולל של 8,000 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום ולאחר מכן ישא ריבית והצמדה כחוק.

ניתן היום, י"ד טבת תשע"ג, 27 דצמבר 2012, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון,

מפקחת על רישום המקרקעין